

1511196-75.2020.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214037/2020 - DEL.POL.ARARAS, 13283657 - DEL.POL.ARARAS, 2796/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2214037 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO VINICIUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511196-75.2020.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511196-75.2020.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214037/2020 - DEL.POL.ARARAS, 13283657 - DEL.POL.ARARAS, 2796/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2214037 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO VINICIUS FELIPPE MONTEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado REINALDO VINICIUS FELIPPE MONTEIRO já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 30 de agosto de 2020, por volta de 21h30, na Rua do Pedreiro, defronte ao nº 112, bairro José Ometto, nesta Cidade e Comarca, o réu trazia consigo, para fins de comercialização, 16 porções de cocaína, pesando cerca de 18,0g (dezoito gramas), e 27 porções de maconha, pesando aproximadamente 52,0g (cinquenta e dois gramas); substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 114) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 162/165). A denúncia foi recebida em 26 de março de 2021 (fls. 170) e o acusado foi devidamente citado. Durante a instrução foram ouvidas

duas testemunhas, bem como interrogado o acusado (fls. 219/221).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 217/218). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou, em suma, seja o réu absolvido por falta de provas.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, improcede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 24/26), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27), pelas fotografias (fls. 28/32) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 118/120), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria também é incerta. Vejamos:

Interrogado, o réu Reinaldo Vinicius Felipe Monteiro disse que, no dia dos fatos, estava em um churrasco com sua esposa quando policiais entraram na casa, cujo portão estava aberto, e abordaram-no. O réu indagou os policiais sobre o que estaria acontecendo e teve como resposta que se tratava apenas de uma abordagem corriqueira. Reinaldo afirma não ter atrapalhado a abordagem, bem como que com ele nada fora encontrado. Contudo, os policiais o algemaram e o levaram para dentro da viatura. Enquanto estava dentro da viatura, o réu viu que os policiais arrombaram o portão de uma casa próxima a sua, vendo também um homem correr. Segundo o réu, foi nesta segunda residência que foram localizados os entorpecentes, não sabendo, o acusado, informar o que ou a exata quantidade do material apreendido. O acusado foi levado preso, sendo que no caminho da delegacia os policiais fizeram uma parada numa "biqueira". O réu aduz que os entorpecentes não eram seus e que acredita ter sido confundido pelos policiais. Afirma, ainda, que não são seu os chinelos apreendidos pelos guardas na casa onde encontraram a droga e que, de forma alguma, correu, tentou fugir, pulou muro ou, sequer, estava nesta segunda casa no momento da prisão, reiterando que se encontrava num churrasco em família (fls.221).

A testemunha Anilton dos Santos, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu vendendo droga para um usuário. Ao perceberem que seriam abordados, o usuário correu e o acusado adentrou numa casa abandonada utilizada para comércio de entorpecentes. Ato contínuo, o acusado passou a pular alguns muros com o intuito de fugir da abordagem policial. Cerca de três casas à cima desta mencionada estava acontecendo um churrasco, os policiais entraram nesta residência com a permissão da proprietária e conseguiram localizar o réu. A testemunha ressaltou que, no momento da fuga, o acusado deixou para trás os chinelos que foram localizados e que, no momento da prisão do acusado, ele encontrava-se descalço. Ademais, o acusado também deixou para trás 27 porções de maconha e 16 pinos de cocaína, bem como pequena quantia em dinheiro, que de igual modo foram apreendidos pelos guardas. A testemunha relata que já conhecia o réu de abordagens anteriores e que, apesar da alegação do réu em estar no referido churrasco junto da esposa, esta não se manifestou no momento da prisão em flagrante, sendo que a mulher que permitiu a entrada dos guardas na casa onde estava acontecendo o churrasco negou que o réu estivesse ali antes (fls. 219).

A testemunha Guilherme Henrique Ventavoli, policial militar, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando, num ponto famoso por vendas de drogas, avistou o réu comercializando entorpecentes com um usuário. Ao avistarem as viaturas, o usuário empreendeu fuga e o acusado adentrou numa casa, correndo aos fundos e pulando os muros. O réu foi encontrado três casas para cima da qual ele havia adentrado. Nesta casa onde o acusado fora localizado estava ocorrendo um churrasco

familiar, cujas pessoas que ali estavam negaram que o réu estivesse ali antes participando daquele evento. Contudo, o acusado afirmava que já estava naquele churrasco anteriormente na companhia de sua esposa. A testemunha reafirma que o acusado, durante a fuga, deixara para trás seus chinelos e uma garrafa pet com entorpecentes. O policial já conhecia o réu de outras abordagens em decorrência de tráfico de drogas. Esclarece, ademais, que a referida garrafa com os entorpecentes estavam próximo ao portão da casa onde o réu entrou na primeira vez (fls. 220).

Essas são as provas dos autos. A absolvição é medida imperiosa.

Conforme já mencionado às fls.222, "Segundo a tese veiculada na denúncia e apresentada pelo guardas desde a fase investigativa, o réu foi preso em casa alheia tentando se misturar aos participantes de um churrasco. O réu, por sua vez, alega que estava em festa com familiares. Há, portanto, divergência sobre ponto relevante.

Certo é que poderia o acusado ter arrolado como testemunha seus familiares. De qualquer forma, isso não exime o Estado do ônus de provar os fatos descritos na denúncia, inclusive tal circunstância de alta relevância. Bastaria, para tanto, ter ouvido já em inquisitiva a testemunha referida pelos guardas e sequer qualificada nos autos."

O ofício expedido pelo juízo foi respondido às fls.242/244, mas nada de relevante trouxe aos autos.

Respeitados os louváveis entendimentos em sentido contrário, sou pela ilegalidade da ação dos guardas municipais que, no caso em apreço, extrapolaram suas atribuições constitucionais.

Realizaram, de fato, verdadeiro patrulhamento preventivo e, mais grave ainda, atividade investigativa, invadindo casas ao arrepio da lei e fora de suas atribuições.

Não se pode admitir que o Estado aja fora dos limites legais.

Sob o argumento de repressão ao crime, por mais grave que seja, não pode nos levar ao "vale tudo" em matéria probatória. Existem regras e sua inobservância tem consequências processuais que invalidam aquelas obtidas ilegalmente.

Nesse sentido, o simples fato de ter sido a prisão por Guardas Civis Municipais não a invalida, em caso de flagrância delitiva, com base no art. 301, do CPP. Todavia, não é esse o caso destes autos.

No caso, os guardas civis municipais exerceram função típica de polícia ostensiva, incumbida constitucionalmente à Polícia Militar, bem como a seguir, ao vasculhar casas, de se reconhecer que houve também trabalho investigativo, cabível à Polícia Civil.

Com essa conduta, os guardas civis municipais infringiram o disposto no artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

De fato, policiamento ostensivo incumbe exclusivamente à Polícia Militar e a função investigativa compete à Polícia Civil, enquanto que os municípios podem constituir Guardas Civis para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Não se desconhece que qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como acima já disposto e como disciplina o Código de Processo Penal, em seu artigo 301.

Dessa forma, ilegal e inconstitucional a ação dos guardas civis municipais.

Não se ignora igualmente que, regulamentando a norma constitucional, foi editada a Lei Federal de nº 13.022/2014, que estabeleceu as competências das guardas civis municipais.

Entretanto, nem mesmo essa mencionada lei autoriza as guardas civis municipais a exercerem atividades típicas da polícia militar e da polícia civil, isto é, não estão legalmente autorizadas a realizar policiamento ostensivo e investigativo, o que os guardas civis praticaram no caso concreto.

Sobre esse tema, inclusive, o Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 154.743-0/0-00 (autos nº 9039481-58.2007.8.26.0000), realizado em 10 de dezembro de 2008, em voto condutor da lavra do Eminente e Culto Desembargador, Doutor Maurício Ferreira Leite, teve oportunidade de decidir e nos ensinar que:

"(...) A faculdade outorgada aos municípios de criação de suas guardas não lhes concede o direito de extrapolar os limites ali impostos, ou seja, visam unicamente a proteção de seus bens, serviços e instalações, devendo ser repelida qualquer tentativa de alargamento desse horizonte, quando mais se constatada invasão a outras esferas."

O Recurso Extraordinário, que recebeu o nº 608.588/SP, no Excelso Supremo Tribunal Federal, que ainda pende de julgamento, já que foi reconhecida a repercussão geral, em decisão proferida pelo Relator, o Eminente Ministro Luiz Fux, no dia 23 de maio de 2013.

Em 10 de março de 2021, o ilustre Procurador-Geral da República, nos referidos autos do Recurso Extraordinário nº 608.588/SP, fez constar que "Estão fora das atribuições constitucionais das guardas municipais as atividades que extrapolem a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, como as de policiamento ostensivo fora desse contexto, as de polícia judiciária e a apuração de infrações penais".

Além disso, se manifestou "(...) pelo parcial provimento do recurso extraordinário, a fim de que se interprete o art. 1º, inciso I, da Lei 13.866/2004 como a autorizar o exercício das atribuições de policiamento preventivo e comunitário exclusivamente no contexto da proteção dos bens, serviços e instalações municipais", e sugeriu a fixação da seguinte tese: "É inconstitucional lei que outorgue à Guarda Municipal atribuições que extrapolem a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, a exemplo das atividades de policiamento ostensivo fora desse contexto, de polícia judiciária e de apuração de infrações penais"

Nesse contexto, atento à estrita legalidade, há que se reconhecer que o ordenamento jurídico só permite ao agente público fazer o que estiver expressamente previsto em lei e, assim, no caso concreto, os guardas municipais não estavam autorizados a investigar um crime, quanto menos da forma como fizeram neste caso, sem terem visto ou presenciado qualquer atitude criminoso do paciente, em verdadeiro combate ostensivo ao crime.

Também nos autos da Apelação Criminal nº 3005009-21.2013.8.26.0038, que tramitou perante a Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, em voto condutor da lavra do Eminente e Culto Desembargador, Doutor Almeida Sampaio, em julgamento realizado em 07 de março de 2016, decidiu-se pela:

"(...) impossibilidade de se validar a ação policial e, por consequência, a ação

penal, por cuidar-se de prova ilegal. Com efeito, a Guarda Municipal não possui poderes constitucionais para efetuar diligências. Sua função não é de policiamento ostensivo. Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma maior perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para efetuar prisão de eventual roubador (...). Poder-se-ia argumentar que cuida-se de prisão em flagrante e que, portanto, qualquer pessoa poderia efetuar-lá. Com efeito, assim se tem decidido. No entanto, neste caso, não se observou esta regra. Os guardas municipais, realizando ato de polícia judiciária, foram fazer investigação. Não se trata, de prisão de pessoa que estava praticando crime, mas foi ela decorrente de diligência, o que não se pode tolerar em razão do que determina a Constituição. Em face do exposto, creio que a prova é contaminada pela ilegalidade e, assim, a ação penal não pode ser reconhecida como válida, devendo, desta forma, ser o acusado absolvido. Observo que a Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, ao conferir o poder de polícia à guarda civil municipal, reafirmou a ilegalidade da ação de policiamento ostensivo por aqueles servidores civis em fatos anteriores à sua vigência, não sendo aplicável ao caso presente, pois os fatos são pretéritos (...)"

Nesse sentido também:

"HABEAS CORPUS Investigação e prisão em flagrante em função típica de policiamento ostensivo, iniciada por ação típica de Polícia Judiciária, por Guardas Cíveis Municipais Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar e/ou à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Relaxado o flagrante, em liminar, confirmada Nulidade processual ab ovo a ser reconhecida Trancamento da ação penal, de ofício, como consequência. Ordem CONCEDIDA". (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2277974-66.2021.8.26.0000)

"Apelação Criminal. Condenação pelo artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Preliminar acolhida. Prova ilícita. Guarda Municipal. Denúncia anônima. Busca domiciliar. Investigação criminal. Patrulhamento ostensivo e realização de busca e apreensão não é função da Guarda Civil Municipal. Inexistência de situação de flagrância. Ilegalidade da prova. Inteligência do artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Guarda civil municipal está destinada à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Absolvição por insuficiência probatória. Apelo parcialmente provido". (TJSP, APELAÇÃO CRIMINAL nº 1502753-49.2019.8.26.0272)

"Crimes de estelionato e corrupção de menores - Reformatio in melius com base no artigo 617 do Código de Processo Penal - Precedentes desta 12ª Câmara de Direito Criminal e do Superior Tribunal de Justiça - Abordagem realizada em função típica de policiamento ostensivo por guardas cíveis municipais e em verdadeira atividade investigativa, funções típicas reservadas constitucionalmente à Polícia Militar e à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Prova ilícita Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO". (TJSP, Apelação Criminal nº 0002166-05.2017.8.26.0068)

Além disso, talvez até por não possuir preparo para ações de tal estirpe, ainda que lícita fosse a conduta dos servidores municipais, deixaram de conduzir à Delegacia testemunhas de suma importância para demonstração da tese acusatória, prejudicando a prova judicial e, assim também a condenação de potencial criminoso.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu REINALDO VINICIUS FELIPPE MONTEIRO, já qualificado nos autos, por falta de provas,

nos moldes da fundamentação, com base no art. 386, VII, do CPP.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos, bem como o perdimento do numerário apreendido, após o trânsito em julgado.

P.R.I.

Araras, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA